

1515673-56.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Ministro Félix Fischer; Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-

9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515673-56.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515673-56.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE WILSON DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos, etc.

André Wilson de Oliveira Souza Santos, qualificado à fl. 08, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, em concurso material com o artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 24 de julho de 2020, por ocasião de estado de calamidade pública, em razão da pandemia de Covid 19, por volta de 16h30 na Rua Tapuias, número 146, no bairro Vila Rodrigues, nesta Comarca de São Paulo, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 7,4 gramas em 77 porções de cocaína, na forma de "crack", 9,3 gramas de tetrahydrocannabinol, em 01 pé de maconha, 18,6 gramas em 26 porções de cocaína e 11, 3 gramas em 01 porção de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 25/29, e ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, recebeu e ocultou, em proveito próprio, um aparelho celular, que sabia ser produto de crime, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 99/2020.

Segundo apurado na data supramencionada, policiais civis realizaram investigações preliminares, e dirigiram-se até a Rua Tapuias 146, a fim de coibir o tráfico de entorpecentes. Os policiais avistaram o réu, próximo a um imóvel de cor verde, segurando uma sacola de plástico preta. Ao avistar os agentes públicos, o réu adotou um comportamento suspeito, demonstrando um enorme nervosismo e, por essa razão, foi abordado. Em revista pessoal, os policiais constataram que André possuía no interior da sacola plástica cédulas diversas de dinheiro que totalizavam o incrível valor de oito mil e cem reais, proveniente do crime de tráfico. O réu também confessou ser o responsável pelo local da venda dos entorpecentes, conhecido vulgarmente como "biqueira". O réu anuiu com a entrada dos policiais no imóvel, ora sua residência, sendo que, após varredura minuciosa, os policiais apreenderam 77 porções de cocaína em forma de "crack", 01 pé de maconha, 26 porções de cocaína e 01 porção de maconha, além de diversas anotações relativas à comercialização de entorpecentes, como constou no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e fotografia de fls. 22. Ademais, os policiais encontraram 03 aparelhos de telefonia celular, sendo que um deles era produto de ilícito penal patrimonial, conforme constou no Boletim de Ocorrência número 1590731/2018. Os entorpecentes foram periciados, conforme constou no laudo de fls. 25/29.

Assim, evidente a atividade narcotraficante desenvolvida pelo réu, considerando a quantidade, diversidade e lesividade das drogas apreendidas em poder do averiguado, e ainda o encontro de incomum quantia em dinheiro, em poder de André, fruto da mercancia espúria.

Denúncia recebida em 03 de setembro de 2020, citado o réu (fl. 127/131), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 134), seguindo-se a instrução, com duas testemunhas e interrogatório ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência parcial da ação penal, com a condenação do réu por crime de tráfico de drogas, nos termos da denúncia, excluído o crime de receptação, por divergência entre o registro de ocorrência de crime patrimonial anterior e auto de exibição e apreensão, que relacionam objetos diversos.

A Defensoria Pública arguiu nulidade do flagrante resultante de violação de domicílio, e no mérito sustentou insuficiência de provas para condenação, impugnando os depoimentos das testemunhas policiais como elemento isolado de prova, subsidiariamente, postulou aplicação de pena mínima, em função das condições pessoais favoráveis e ausência de circunstâncias agravantes, em regime inicial menos gravoso, e a substituição por penas alternativas.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é parcialmente procedente.

Auto exibição e apreensão de fl. 11/12 e auto de constatação prévia de fls. 25/29 indicam 7,4 gramas em setenta e sete porções de cocaína, na forma de "crack", 9,3 gramas de tetrahidrocannabinol, em um pé de maconha, 18,6 gramas em vinte e seis porções de cocaína, e 11,3 gramas em uma porção de maconha.

Apreendidos também três telefones celulares, sendo dois da marca Motorola e outro da marca Apple, diversas folhas contendo anotações financeiras, e a quantia de oito mil e cem reais em diversas cédulas, tudo fotografado à fl. 22.

Boletim de ocorrência de fls. 22/23 atesta a origem ilícita do aparelho celular IMEI: 35961109370299, que não é nenhum dos três relacionados no auto de exibição e apreensão, devendo ser excluído o crime de receptação, por falta de prova da materialidade.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 104/107 positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol.

Em fase inquisitiva, os policiais civis Genildo Nascimento da Fonseca Junior e David Geraldo Ferreira de Souza relataram que, após investigações preliminares, diligenciaram até região de Franco da Rocha/SP em cumprimento de Ordem de Serviço número 39/2020, mais especificamente pela Rua Tapuias, número 146, no bairro Vila Guarani, em Franco da Rocha / SP, no intuito de coibir o tráfico de entorpecentes, cujo gerente/dono das "biqueiras" seria a pessoa de prenome Thiago de Tal, e que uma mulher de prenome Bruna de Tal seria outra responsável pelo abastecimento

local. Chegando ao referido local, os policiais se dirigiram até a residência de cor verde, na qual um indivíduo estava em frente segurando uma sacola de plástico preta, que ao avistar os policiais, demonstrou extremo nervosismo, motivo pelo qual os policiais o abordaram questionando o que havia dentro de tal sacola, sendo que tal indivíduo abriu mostrando aos policiais que havia uma quantia alta em diversas cédulas, confessando informalmente que tal dinheiro era proveniente do tráfico de entorpecentes local, e que o mesmo era responsável pelo abastecimento das conhecidas "biqueiras" (pontos de venda de entorpecentes). Tal indivíduo ainda franqueou a entrada no imóvel de cor verde, sua residência, sendo que após varredura minuciosa dos policiais, localizaram, mais especificamente no quarto do referido indivíduo, dentro do guarda-roupa: 77 unidades de substância petrificada semelhante ao entorpecente comumente conhecido como crack, 26 unidades, sendo 20 invólucros plásticos e 6 eppendorfs contendo substância em pó branco semelhante ao entorpecente comumente conhecido como cocaína, 01 invólucro plástico contendo substância granel semelhante ao entorpecente comumente conhecido como maconha, diversos papéis contendo aparentemente anotações financeiras do tráfico da região, 03 aparelhos de celular, sendo que um dos celulares, o Motorola de cor dourada, estava constando registro de ocorrência de furto de celular, número 1590731/2018, registrado pela Delegacia Eletrônica, e ainda, no quintal foi encontrado 01 pé de planta de maconha in natura. Diante de tal situação flagrancial, os policiais conduziram o indivíduo bem como as substâncias apreendidas até a unidade policial para apreciação da Autoridade Policial e demais providências de Polícia Judiciária. Na lavratura do auto de prisão em flagrante o acusado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em audiência de instrução:

Genildo Nascimento da Fonseca Júnior, Policial Civil, relatou que investigava tráfico de drogas na região central, com informação de que as drogas eram distribuídas por três pessoas, proveniente de Franco da Rocha, e foram feitas cerca de quatro campanhas no local, em busca de uma casa verde e um suspeito identificado como Dé, que seria o responsável pela distribuição das drogas naquela região e no centro de São Paulo, sendo ele observado circulando pelas vielas ao redor da casa, que dificultavam eventual abordagem, até que conseguiram aborda-lo na porta da casa, encontrando com ele mais de oito mil reais, com odor de drogas, então, ele confessou atuar como gerente do tráfico na região, e não informou onde poderiam ser localizados os outros envolvidos, e na casa dele, no guarda roupas, juntamente com os documentos pessoais do réu, foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack, além de três celulares, sendo um deles produto de furto, prosseguindo as investigações, foi instaurado inquérito policial em Franco da Rocha, com análise dos celulares apreendidos, que revelaram envolvimento do réu com tráfico de drogas, envolvendo outros onze traficantes, que foram qualificados e indiciados. Dias depois, o réu foi posto em liberdade e novamente preso em Franco da Rocha, com quantidade ainda maior de drogas e elevada quantia em dinheiro.

David Geraldo Ferreira de Souza, Policial Civil, relatou que investigava crime de tráfico, e averiguava informação sobre distribuição de drogas na rua Tapuias, em cumprimento de ordem de serviço, e em última diligência, encontrou o réu na porta da residência com uma sacola em mãos, na qual havia grande quantia em dinheiro, e questionado, ele disse que era proveniente do tráfico de drogas, e na residência, onde ele morava, no quarto dele, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, além de anotações e celulares, sendo um dos aparelhos produto de crime de furto, e sobre as drogas, ele informalmente admitiu que abastecia pontos de venda na região onde morava. Em ocasião anterior observou o réu saindo da casa e percorrendo vielas pelas imediações em direção a pontos de tráfico, mas achou melhor não segui-lo para evitar se descoberto em situação de inferioridade numérica diante de possíveis traficantes. Não se recorda se o réu apresentou alguma justificativa para a posse do celular de origem ilícita. A partir da quebra de sigilo dos celulares apreendidos, foi desmantelado importante atividade de tráfico envolvendo o réu. Por ocasião dos fatos ele encontrava-se sozinho no local, na calçada em frente à casa.

Interrogado ao final da instrução, o réu negou integralmente a acusação, dizendo

que estava dentro de casa com sua esposa e filhos quando os policiais entraram, perguntando sobre Bruna, e se havia drogas em sua casa, apontando-lhes maconha que tinha em casa, e quanto ao dinheiro, obteve com a venda de uma motocicleta, além disso, possuía três celulares, um deles pertencente a um vizinho, sem saber que era roubado. Após os fatos, foi solto e preso novamente por crime de tráfico, que veio a confessar e foi condenado.

A suposta origem do dinheiro apreendido é desprovida de qualquer elemento de provas, bem como, a possível presença de outras pessoas na residência por ocasião da diligência policial, pessoas que poderiam ter sido arroladas pela defesa. Neste contexto, a prova da apreensão das drogas resulta dos relatos dos policiais, contra os quais não consta nenhum outro elemento de prova, sendo que, se de fato havia mais alguém dentro da casa, familiar do réu, cumpria à defesa arrolar como testemunha, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Baseando-se em tais provas, sobre a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, ao contrário do que sustentou a defesa em alegações finais, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssonos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos. Reporto-me ao entendimento jurisprudencial: Prova criminal - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313. Crime contra a saúde pública - Prova criminal - Depoimento de policial participante de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423.

Quanto ao elemento subjetivo do crime atribuído ao réu, inequivocamente manter em depósito dezenas de porções de drogas variadas caracteriza prova de mercancia ilícita, mesmo porque, o próprio réu afastou a possibilidade da droga destinar-se a consumo pessoal.

Outro indicativo concreto de tráfico de drogas resulta da apreensão de quantia em dinheiro de origem não justificada pelo réu, juntamente com drogas embaladas individualmente e prontas para comercialização. Nesse sentido: "Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível". (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3ª Câ. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).

Também não cabe arguir nulidade do flagrante por preparação ou falta de ordem judicial para permanência dos policiais na residência do réu, na medida em que as provas colhidas no curso da ação penal revelam que não houve instigação, participação ou colaboração dos policiais na posse e comercialização de drogas pelos acusados, tratando-se de crime de natureza permanente, que se consumou desde antes da atuação policial. Nesse sentido: "PRISÃO - Flagrante preparado - Tráfico de tóxico - Compra do produto simulada por policial - Irrelevância - Crime de natureza permanente - Delito já caracterizado antes da simulação - Crime impossível não configurado - Recurso provido" - JTJ 209/284. "PRISÃO - Flagrante preparado - Inocorrência - Tráfico de entorpecente - Crime de natureza permanente - Consumação do delito que preexistiu ao flagrante - Recurso não provido" - JTJ 208/273.

O julgamento recente a que alude a tese de defesa, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sobre a exigência de gravação de imagens ou autorização escrita do réu para que os policiais ingressassem em sua residência, ainda que em situação de flagrante de crime permanente, não recebeu efeitos gerais ou vinculantes, e contraria entendimento consolidado há décadas pelo mesmo tribunal, divergindo inclusive do entendimento atual da 5ª Turma, no sentido de que o crime de tráfico, conduta de caráter permanente, consuma-se antes mesmo da interferência dos policiais, nas modalidades típicas guardar e trazer entorpecentes, para posterior entrega de qualquer forma a terceiros. A mesma temática já foi abordada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, no RHC 53.659, circunstância que afasta qualquer

ilicitude a macular a provar produzida. Nesse sentido: "Violação de domicílio - Inocorrência - Ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência, em que se realizava comércio ilícito de entorpecente - Garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio que é inaplicável nos casos de flagrante delito - Inteligência do art. 5º, XI da Constituição Federal. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio cede espaço nos casos de flagrante delito (CF, art. 5º, XI), não merecendo censura a ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência em que se realizava comércio ilícito de entorpecente, em especial quando a entrada ocorreu sem arrombamento." (STJ - RT 771/565).

Em julgamento mais recente, publicação DJe 08/04/2021, a Egrégia 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou entendimento contrário ao julgado invocado pela defesa, do qual destaco trecho específico sobre o tema questionado: AgRg no RHC 143123/MG, Relator Ministro Félix Fischer; Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses."

Procedente em parte a ação penal, excluído o crime de receptação dolosa. Passo ao cálculo das penas, nos termos dos artigos 42 da Lei 11343/06 e do artigo 68 do Código Penal.

O réu ostenta condenação recente por crime de tráfico de drogas, pendente de recurso, não sendo considerado reincidente para efeitos do artigo 63 do Código Penal. Além disso, demonstrou envolvimento em atividade organizada de tráfico de drogas, pois, além de drogas variadas, em quantidade que não deve ser considerada desprezível, também possuía elevada quantia em dinheiro, cuja origem não justificou, e três, além de anotações contábeis típicas de tráfico, e três telefones celulares, que demonstram maior nível de articulação de sua atividade criminosa. Inviável, pois, aplicação da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11343/06. Bem assim, a quantidade de droga e variedade das drogas apreendidas, dezenas de porções prontas para comercialização, revela potencial de dano difuso à saúde pública devido ao grande número de usuários faz incidir a regra do artigo 42 da Lei nº 11.343, afastando a aplicabilidade da aludida causa especial de redução de pena, excluindo o requisito subjetivo previsto em caráter excepcional para essa regra de cálculo da pena. Partindo-se da pena base de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, para o crime de tráfico de drogas, na segunda fase da dosimetria, presente circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, prevê circunstância objetiva da conduta, consistente em praticar crime em "qualquer calamidade pública", isto é, quem praticar crime em tal circunstância, independentemente de sua intensão, receberá tratamento legal diferenciado. O Decreto número 64879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo decorrente da pandemia do Covid-19, foi largamente divulgado por todos meios de comunicação, de conhecimento, sendo inviável alegar ignorância da situação atual de pandemia. Inequívoco, portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação da doença e contágio coletivo, risco que o traficante assumiu e será apenado proporcionalmente à gravidade da conduta criminosa, justificando-se acréscimo de pena de 1/6, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias multa. Não constam outras circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, e o tempo de

prisão descontado desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal não é compatível com a gravidade da conduta, ponderados os mesmos fundamentos da dosimetria da pena, tratando-se de conduta de consequências diferenciadas que atenta seriamente contra a ordem pública e acarreta manifesto risco à ordem e segurança pública, fomento de diversas atividades criminosas ainda mais graves, merecedora de tratamento legal diferenciado, em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta pelo criminoso que se dispõe a distribuir drogas em bairro residencial densamente habitado, de modo a expor a risco não só os usuários como potenciais adquirentes de drogas ilícitas, mas principalmente todos aqueles que, alheios à sua atividade criminosas, são obrigados a conviverem diariamente sob a nefasta ameaça do tráfico de drogas. O tempo de prisão desde a data do flagrante não enseja antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 112 da LEP e do artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal.

Os dias multa serão calculados em valor unitário equivalente a meio salário mínimo vigente, em proporção à condição econômica revelada pelo réu, surpreendido por ocasião do flagrante com elevada quantia em dinheiro, demonstrando que auferia elevados rendimentos com sua atividade criminosa, em aplicação do disposto no artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, para condenar o réu André Wilson de Oliveira Souza Santos, qualificado à fl. 08, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias multa, calculados em valor unitário equivalente a meio salário mínimo vigente.

Com fundamento no artigo 63, I, da Lei 11343/06, determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, produto de crime de tráfico, que será revertida ao FUNAD. Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp, suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

O réu foi preso em flagrante, beneficiado com liberdade provisória, e novamente preso por crime de tráfico, permanecendo preso por outro processo, e subsistentes os fundamentos da prisão cautelar mantida no curso da instrução, conforme decidido no curso da ação penal, não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 8072/90. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA